

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Peculato (art. 312 do CP)

Vamos entender o Peculato.

Será uma conversa informal, onde pretendo ajudar você a entender a matéria, mostrando as situações que aparecem recorrentemente nos concursos.

Acompanhe comigo o raciocínio, **vamos “construir” o crime de peculato**. Acredito que no final do capítulo você estará apto a acertar sua questão de peculato.

Vamos lá.

Respire e não perca a linha de raciocínio.

Assim como todo crime praticado por funcionário público contra a Administração em Geral, o PECULATO é classificado como um crime próprio de funcionário público.

Mas qual objeto material do crime de peculato?



Tome nota!

ESSA É A 1ª REGRINHA DO PECULATO: TEM COMO OBJETO MATERIAL - DINHEIRO, VALOR OU QUALQUER OUTRO BEM MÓVEL, PÚBLICO OU PARTICULAR.

Acho que é boa hora para você entender a origem da palavra PECULATO.

Peculato vem do latim “*PECUS*”, que significa “GADO”.

Gado? Sim, Gado, boi. Não é atoa a criação de gado é chamada “PECUária”. Que o criador de gado é chamado de “PECUarista”.

Mas o que *gado* tem haver com crime?

Conta brilhantemente Nelson Hungria (*Comentários ao Código Penal, Volume IX, pg. 330*) que na antiguidade romana, o gado (*pecus*) era utilizado para SACRIFÍCIOS para DEUSES. Por isso, o gado (*pecus*) era considerado uma RIQUEZA PÚBLICA. Grosso modo, podemos dizer que o gado (*pecus*) era um PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Então quando alguém se “apropriava” de um *pecus*, estava se “apropriando” um bem público, cometendo *PECUS-LATO* (PECULATO).

Hoje, nossas riquezas públicas são outras e o objeto material do peculato não é mais o gado; e sim DINHEIRO, VALOR OU QUALQUER OUTRO BEM MÓVEL, PÚBLICO OU PARTICULAR.

Há uma clara relação do termo “*pecus*” com DINHEIRO.

Deriva do termos “*pecus*” o termo “*peculium*”, e conseqüentemente, a palavra PECÚNIA. Opa, pecúnia você já ouviu falar né. Pecúnia é sinônimo de DINHEIRO, VALOR.

Então faça a conexão: “*pecus*” (gado) - “*peculium*” - pecúnia – dinheiro, valor.

Voltando a nossa 1ª Regrinha, o objetivo material do peculato é DINHEIRO, VALOR OU QUALQUER OUTRO BEM MÓVEL, PÚBLICO OU PARTICULAR.

Atenção, **o objeto do crime de peculato só poderá ser BEM MÓVEL** (seja dinheiro, valor ou OUTRO bem móvel). Em outras palavras, dinheiro e valor também é BEM MÓVEL.

Se a questão falar em bem IMÓVEL, não é peculato.

Importante: **não existe peculato de serviço**. *O que é isso? Suponha que o chefe de um repartição pública tenha que pagar umas contas no banco. Para isso manda teu subordinado ir até o banco fazer esse “servicinho particular”. Tal fato é totalmente condenado, mas não configura peculato. Não configura porque o objeto material não é um bem móvel, e sim um serviço. Portanto, **não existe peculato de serviço**. O chefe poderá ser punido administrativamente, mas não cometeu peculato.* **Atenção**, você precisa saber disso: O PREFEITO que utiliza indevidamente serviços públicos comete um crime previsto no Decreto-lei n. 201/67. Portanto, o prefeito responde criminalmente pelo utilização indevida de serviços públicos.

Cuidado: bem móvel **particular** também pode ser objeto material do peculato (essa caso também é chamado de Peculato “**Malversação**”, ou seja, Peculato de “**má administração**” do bem alheio).

Vamos lá. Concentração.

Qual a relação do funcionário público com esse objeto material (dinheiro, valor ou outro bem móvel)?



ESSA É A 2ª REGRINHA DO PECULATO: O FUNCIONÁRIO PÚBLICO DEVE TER POSSE EM RAZÃO DO CARGO.

POSSE EM RAZÃO DO CARGO. Repetindo porque cai muito: POSSE EM RAZÃO DO CARGO.

Se não houver POSSE, em regra, NÃO HÁ PECULATO.

Se houve POSSE, e a essa POSSE ocorrer por outro motivo que **NÃO SEJA O CARGO PÚBLICO**, NÃO HÁ PECULATO.

Vou exemplificar:

*Um funcionário público municipal, em sua folga, passa por uma rua qualquer, e vê um carro da Prefeitura parado. Ele arromba o carro e o leva embora. Cometeu Peculato? NÃO, porque a POSSE DO CARRO **NÃO SE DEU EM RAZÃO DO CARGO**. O crime cometido foi outro, mas não peculato.*

Agora o mesmo funcionário público municipal, trabalha com um carro oficial para exercer suas funções de fiscalização. NESSE CASO, HÁ POSSE EM RAZÃO DO CARGO. Se ele se apropria do carro, levando para casa como se fosse seu, terá cometido PECULATO.

Entenda que para ocorrer PECULATO essa POSSE se dá em razão das funções exercidas pelo funcionário público. Melhor dizendo, a POSSE do bem é LEGÍTIMA, mas apenas para AJUDAR ou EM RAZÃO das funções do funcionário público.

Exemplificando: “o fiscal ou caixa de banco público tem POSSE do dinheiro que arrecada ou recebe”; “o escrivão de polícia tem POSSE do seu computador de trabalho”; “o policial tem POSSE do veículo que apreende”. São todos casos de POSSE EM RAZÃO DO CARGO.

Mas há uma exceção importante: há uma modalidade de peculato chamada de peculato-furto em que **não há posse**. Grave só isso por enquanto. Vamos explicar certinho o que é peculato-furto. Por enquanto, saiba só que **no peculato-furto NÃO HÁ POSSE**.

Reprisando:



Fique ligado!

1ª REGRINHA DO PECULATO: TEM COMO OBJETO MATERIAL, DINHEIRO, VALOR OU QUALQUER OUTRO BEM MÓVEL, PÚBLICO OU PARTICULAR.

2ª REGRINHA DO PECULATO: O FUNCIONÁRIO PÚBLICO DEVE TER POSSE EM RAZÃO DO CARGO.

Até agora vimos que *em razão de seu cargo, o funcionário público tem a posse em de um bem móvel*.

Mas o que ele faz de “errado” para virar crime?



Tome nota!

ESSA É A 3ª REGRINHA DO PECULATO: O FUNCIONÁRIO PÚBLICO **APROPRIA-SE** (PECULATO-APROPRIAÇÃO) OU **DESVIA** (PECULATO-DESVIO) O BEM MÓVEL QUE TEM POSSE EM RAZÃO DO CARGO.

Bem, já podemos transcrever o texto do Código Penal que incrimina o Peculato:



Importante!

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

Veja bem que essas **duas condutas** distintas podem gerar o peculato:

1 - **Apropriar-se** do dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo. Esse é o chamado **PECULATO-APROPRIAÇÃO**.

O bem considera-se **apropriado** quando é assenhorado, ou seja, quando o funcionário público passa a agir **como se fosse dono do bem**. Grosso modo, **apropria-se** é “*pegar para si*”.

Agora pergunto: e o funcionário público que usa o bem público para fins particulares, mas depois devolve para Administração, comete peculato? Por exemplo, o funcionário que usa o automóvel da Administração Pública para resolver “coisinhas” particulares.



Jurisprudência

NÃO. NÃO HÁ PECULATO DE USO. Tal resposta foi dada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 108433, em 25/06/2013, em acórdão relatado pelo Ministro Luiz Fux:

“É ATÍPICA A CONDUTA DE PECULATO DE USO”.

Ressalva-se que no caso do funcionário que usa o automóvel da Administração Pública para resolver “coisinhas” particulares, existe a possibilidade de interpretação do peculato do “combustível”. Isso já foi explorado em questões. É importante ficar atento. Ainda sobre o peculato de uso, temos que tomar cuidado com o crime previsto no DL n.º 201/67::

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

(...)

II - utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos;

Vamos para a segunda conduta.

2 - **Desviar**, em proveito próprio ou alheio, dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo. É o **PECULATO-DESVIO**.

O bem considera-se **desviado** quando é utilizado para finalidade (destinação) diversa. Além disso, é necessário que se tenha “*proveito próprio ou alheio*”.

Nesse ponto merece destaque que o proveito não precisa ser necessariamente financeiro, pode ser um proveito moral.



Jurisprudência

RAMO DO DIREITO DIREITO PENAL TEMA Peculato-desvio. Desconto de valores dos contracheques dos servidores para quitação de empréstimos consignados. Não repasse à instituição financeira. Demonstração do proveito próprio ou alheio. Desnecessidade. DESTAQUE O administrador que desconta valores da folha de pagamento dos servidores públicos para quitação de empréstimo consignado e não os repassa a instituição financeira pratica peculato-desvio, sendo desnecessária a demonstração de obtenção de proveito próprio ou alheio, bastando a mera vontade de realizar o núcleo do tipo.

INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR De início, ressalta-se que a diferença entre manipulação de dinheiro público ou particular tem especial importância na análise da questão do dolo na obtenção de proveito próprio ou alheio com desvio de finalidade das verbas e da simples aplicação inadequada dessa mesma verba. Essa discussão, que eventualmente surge na hipótese de o administrador público dar destino diverso ao previsto para a verba, mas ainda no âmbito público, a exemplo de deslocar montante que seria aplicado à saúde para a pavimentação de rodovia. Contudo, sendo o dinheiro particular, esse tipo de controvérsia se desfaz, pois não é dado ao administrador deslocar esse dinheiro para nenhuma outra finalidade que não a ajustada. Assim, tratando-se de aplicação de dinheiro particular e tendo o administrador público traído, evidentemente, a confiança que lhe fora depositada, ao dar destinação diversa à ajustada, não é requisito para a configuração do crime a demonstração do proveito próprio ou alheio. Mesmo que necessário fosse, sendo o dinheiro de servidores, ou seja, particular, o proveito exsurge do fato em si. O peculato-desvio é crime formal que se consuma no instante em que o funcionário público dá ao dinheiro ou valor destino diverso do previsto. A obtenção do proveito próprio ou alheio não é requisito para a consumação do crime, sendo suficiente a mera vontade de realizar o núcleo do tipo. Desse modo, configura peculato-desvio a retenção dos valores descontados da folha de pagamento dos servidores públicos que recebiam seus vencimentos já com os descontos dos valores de retenção a título de empréstimo consignado, mas, por ordem de administrador, os repasses às instituições financeiras credoras não eram realizados. (Informativo 664) APn 814-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Rel. Acórd. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 06/11/2019, DJe 04/02/2020.

Se o **desvio** gerar um **proveito para a própria Administração Pública**, não haverá peculato, e sim “*Emprego Irregular de Verbas ou Rendas Públicas*”.



Grave uma exceção importante: há uma **lei especial** para o peculato-apropriação e o peculato-desvio de **Prefeitos**. Assim, quando os prefeitos praticam tais condutas não se aplica o Código Penal, e sim essa lei especial (princípio da especialidade). Trata-se do do Decreto-lei n. 201/1967, que assim dispõe:

*“Art. 1.º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:
I – **apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;**”*

Ressalta-se que **só** não aplicam ao Prefeito o peculato-apropriação e o peculato-desvio do Código Penal. Ainda vamos estudar o perculato-furto e o peculato culposa, e esses crimes aplicam-se perfeitamente aos Prefeitos, visto que não encontram correspondente (igual) crime na lei especial (Decreto-Lei n. 201/1967).

Voltando ao Peculato, essas duas condutas (Peculato-Apropriação e Peculato-Desvio) geram o peculato propriamente dito, ou seja, são modos **PRÓPRIOS** (normais) de cometer peculato.

Por isso, quando a questão falar em **PECULATO PRÓPRIO** está falando do **PECULATO-APROPRIAÇÃO** e do **PECULATO-DESVIO**.

Se há formas **próprias** (normais) de cometer o peculato, significa que há uma forma **IMPRÓPRIA**.

Essa forma imprópria de peculato é o chamado de **peculato-furto**.

Ela é considerada imprópria (anormal) porque **não há posse, não há apropriação, não há desvio**.

Como o próprio nome já diz, no peculato-furto há uma **SUBTRAÇÃO**.

Essa subtração não ocorre porque o funcionário tem posse do bem em razão do cargo. Mas **devido a FACILIDADE que a qualidade de funcionário público lhe proporciona para cometer tal delito**.

Vou exemplificar: João (funcionário público) não é responsável pelo estoque de bens da repartição, mas, como é funcionário público, tem fácil acesso a esse estoque. Assim, um belo dia, durante o horário de almoço, entra no depósito e subtrai alguns bens. Ele cometeu peculato-furto.



Tome nota!

ESSA É A 4ª REGRINHA DO PECULATO: NO PECULATO-FURTO (IMPRÓPRIO), O FUNCIONÁRIO NÃO TEM POSSE DO BEM, MAS DEVIDO A FACILIDADE QUE SUA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO LHE PROPORCIONA, ELE SUBTRAI DINHEIRO, VALOR OU BEM.

Se para subtrair o bem, o funcionário público não utilizar da facilidade que a condição de funcionário público lhe proporciona, não responderá por peculato-furto. Responderá por furto.

Assim, construímos mais um pouco do Peculato:



Importante!

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário .

Fixe bem as regrinhas:



Fique ligado!

1ª REGRINHA DO PECULATO: TEM COMO OBJETO MATERIAL, DINHEIRO, VALOR OU QUALQUER OUTRO BEM MÓVEL, PÚBLICO OU PARTICULAR.

2ª REGRINHA DO PECULATO: O FUNCIONÁRIO PÚBLICO DEVE TER POSSE EM RAZÃO DO CARGO.

3ª REGRINHA DO PECULATO: O FUNCIONÁRIO PÚBLICO APROPRIA-SE (PECULATO-APROPRIAÇÃO) OU DESVIA (PECULATO-DESVIO) O BEM MÓVEL QUE TEM POSSE EM RAZÃO DO CARGO

4ª REGRINHA DO PECULATO: NO PECULATO-FURTO (IMPRÓPRIO), O FUNCIONÁRIO NÃO TEM POSSE DO BEM, MAS DEVIDO A FACILIDADE QUE SUA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO LHE PROPORCIONA, ELE SUBTRAI DINHEIRO, VALOR OU BEM.

Estamos terminando.

Até agora tudo que falamos se referia ao peculato intencional, ou seja, ao PECULATO DOLOSO.

O Código Penal define o que é crime DOLOSO e CULPOSO:

Art. 18 – Diz-se o crime:

I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;

II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

O crime doloso, por razões óbvias, deve ser punido. E o crime culposo, é punido?

O parágrafo único do citado art. 18 fala assim:

Art. 18 (...)

*Parágrafo único - **Salvo os casos expressos em lei**, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente.*

Como visto, em regra, só se pune o crime doloso. O crime culpososó será punido **nos casos expressos em lei**, ou seja, a lei tem que dizer expressamente que TAL CRIME é punido se cometido na forma CULPOSA.

Agora vem a pergunta: o peculato é punido na forma culposa? Em outras palavras, se devido a imprudência, a negligência ou a imperícia do funcionário público, ocorrer o peculato, ele será punido?



Tome nota!

ESSA É A 5ª REGRINHA DO PECULATO: O PECULATO É O **ÚNICO** CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PUNÍVEL NA FORMA **CULPOSA (PECULATO CULPOSO)**.

Isso porque o Código Penal assim quis:



Importante!

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Quer dizer que mesmo sem intenção, apenas em razão de um “vacilo”, o funcionário público vai cometer um crime (peculato culposos)? Será considerado um “criminoso”? Sim.

Mas é muito pesado.

É, e por ser tão pesado é que o Código Penal resolveu dar duas “chances” para o funcionário público acusado de peculato-culposos.

A PRIMEIRA CHANCE é a seguinte: **Se o funcionário REPARAR DO DANO (“pagar”) antes de sentença IRRECORRÍVEL (Trânsito em Julgado), será EXTINTA A PUNIBILIDADE**, ou seja, não haverá punição.

Mas o funcionário queria “brigar” até o fim na Justiça, não reparou o dano e a sentença se tornou irrecorrível (transitou em julgado). Ainda assim, mesmo condenado, sem possibilidades de recursos judiciais, ele terá uma SEGUNDA CHANCE: **SE REPARAR O DANO, TERÁ SUA PENA REDUZIDA PELA METADE.**



Tome nota!

ESSA É A 6ª REGRINHA DO PECULATO: NO PECULATO CULPOSO, SE O FUNCIONÁRIO REPARAR O DANO ANTES DE SENTENÇA IRRECORRÍVEL, EXTINGUIRÁ A PUNIBILIDADE. SE REPARAR DEPOIS DA SENTENÇA IRRECORRÍVEL, TERÁ SUA PENA REDUZIDA PELA METADE.

Finalizamos assim a “construção” do PECULATO.

Antes de terminar vamos falar de um tema moderno: o princípio da insignificância.

A ideia é a seguinte:

As teorias penais antigas entendem que para caracterizar um crime basta ocorrer o fato descrito no tipo penal. Em outras palavras, basta a conduta praticada ser a conduta prevista na lei penal. É a chamada tipicidade formal. *Por exemplo, quem furta um pão para dar ao filho comete FORMALMENTE o crime de FURTO.*

As teorias penais modernas entendem que além dessa tipicidade formal há também necessidade de SIGNIFICATIVA lesão ao bem jurídico protegido pela lei penal. *Pela teoria moderna, NÃO há crime no caso do "furto do pão", pois não houve SIGNIFICATIVA lesão ao patrimônio (bem protegido). Não houve TIPICIDADE MATERIAL. Trata-se do PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, ou seja, para ser crime a lesão ao bem jurídico deve ser SIGNIFICANTE.*

E no crime de peculato: aplica-se o PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA? Agora vem a notícia triste, há divergências.

No STJ prevalece o entendimento que NÃO É POSSÍVEL, pois nos crimes contra a Administração Pública não se protege apenas o patrimônio público, mas também a MORALIDADE PÚBLICA, então, o simples desvio de conduta é SIGNIFICANTE, o dever de moralidade do funcionário público impera.

No entanto, o STF vem admitindo em alguns casos a aplicação do PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA nos crimes contra a Administração Pública.

Na hora da prova, veja o contexto, se não falar nada sobre entendimentos do STF ou do STJ, eu optaria em marcar que **não é aplicável**. Entretanto, de qualquer modo, a questão será passível de anulação.

Leia o resumo. Fixe.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

E falou Jesus: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei". Mateus 11:28

Resumo

PECULATO

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.

§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

1ª REGRINHA DO PECULATO: TEM COMO OBJETO MATERIAL, DINHEIRO, VALOR OU QUALQUER OUTRO BEM MÓVEL, PÚBLICO OU PARTICULAR.

2ª REGRINHA DO PECULATO: O FUNCIONÁRIO PÚBLICO DEVE TER POSSE EM RAZÃO DO CARGO.

3ª REGRINHA DO PECULATO: O FUNCIONÁRIO PÚBLICO APROPRIA-SE (PECULATO-APROPRIAÇÃO) OU DESVIA (PECULATO-DESVIO) O BEM MÓVEL QUE TEM POSSE EM RAZÃO DO CARGO.

4ª REGRINHA DO PECULATO: NO PECULATO-FURTO (IMPRÓPRIO), O FUNCIONÁRIO NÃO TEM POSSE DO BEM, MAS DEVIDO A FACILIDADE QUE SUA CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO LHE PROPORCIONA, ELE SUBTRAI DINHEIRO, VALOR OU BEM.

5ª REGRINHA DO PECULATO: O PECULATO É O ÚNICO CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PUNÍVEL NA FORMA CULPOSA (PECULATO CULPOSO).

6ª REGRINHA DO PECULATO: NO PECULATO CULPOSO, SE O FUNCIONÁRIO REPARAR O DANO ANTES DE SENTENÇA IRRECORRÍVEL, EXTINGUIRÁ A PUNIBILIDADE. SE REPARAR DEPOIS DA SENTENÇA IRRECORRÍVEL, TERÁ SUA PENA REDUZIDA PELA METADE.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960